

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4643/2536

นาง ปู้จู้ แซ่ตันหรือกุลพัฒนโสภ ณ  
นาย ต่อ งหวั อูยเอ็ง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 182, มาตรา 183, มาตรา 243 (1)

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ที่ดินโจทก์อยู่ในที่ปิดล้อม ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ โจทก์ใช้เส้นทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่นหลายรายและผ่านที่ดิน น.ส.3 ของจำเลยเข้าสู่ที่ดินของโจทก์ตามเส้นทางที่ระบุว่า "ทางชักลากไม้" ตั้งแต่ปี 2508 ถึง เดือน มิถุนายน 2526 โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเกี่ยวข้องคัดค้านตามคำบรรยายฟ้องแสดงให้ เห็นว่า ทางพิพาทเป็นทางจำเป็น ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่าขลย 2. โจทก์มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ 3. ทางพิพาทตามเส้นประสีเหลืองในแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 เป็นทางจำเป็นและหรือทางภาระจำยอมหรือไม่ ขลย โดยมีได้กำหนดว่าทางพิพาทเป็น ทางสาธารณะหรือไม่ไว้ด้วย แต่ครั้งเมื่อทำคำพิพากษา ศาลชั้นต้นให้เพิกถอน ประเด็นข้อ 2 ข้อ 3 เสียแล้วกำหนดประเด็นสองข้อนี้เสียใหม่เป็นว่าโจทก์มีอำนาจให้ จำเลยเปิดทางพิพาทตามเส้นประสีเหลืองในแผนที่เอกสารหมายเลข 1 ได้หรือไม่ เพียงใด ตามประเด็นใหม่ครอบคลุมประเด็นข้อที่ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ เข้าไปด้วยซึ่งประเด็นข้อนี้เดิมศาลไม่ได้กำหนดไว้ คู่ความมิได้โต้แย้งคัดค้าน ถือว่าคู่ความสละไปแล้ว การที่ศาลชั้นต้นนำประเด็นข้อที่ว่าทางพิพาทเป็นทาง สาธารณะหรือไม่ มาวินิจฉัย จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบ แต่เมื่อคดีขึ้นสู่ ศาลฎีกาแล้ว ประกอบกับคู่ความได้นำสืบพยานหลักฐานตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้

ตอนแรกครบถ้วนแล้วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน ที่ดินของโจทก์มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทหรือทางชักลากไม้ที่ปรากฏในน.ส.3 ผ่านเข้าออกสู่ที่ดินของโจทก์ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2526 แม้จะมีทางอื่นเข้าออกได้อีกทางหนึ่ง แต่ก็เป็นที่ดินชั้นเขา มีลักษณะลาดชัน ไม่อาจใช้รถยนต์วิ่งผ่านได้และไกลกว่าทางพิพาท ทางพิพาทจึงเป็นทางจำเป็น สภาพทางพิพาทเป็นทางที่ชาวบ้านลากไม้ กว้างประมาณ 1 เมตรเศษ นอกจากร่องรอยทางเดินเท้าแล้ว ไม่มีร่องรอยทางรถยนต์ ปรากฏตามรายงานการเผชิญสืบของศาลว่าทางพิพาทก็กว้าง 1.50 เมตร ศาลชั้นต้นกำหนดความกว้างของทางพิพาทให้ 1.50 เมตร เป็นการสมควรแล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตราจองเลขที่ 13 ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในที่ปิดล้อมไม่มีทางผ่านออกสู่ถนนสาธารณะ โจทก์ใช้เส้นทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่นหลายราย และผ่านที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 195 ซึ่งเป็นของจำเลยเข้าสู่ที่ดินของโจทก์ตามเส้นทางที่ระบุว่าเป็นทางชักลากไม้ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงเดือนมิถุนายน 2526 โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเกี่ยวข้องคัดค้าน ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2526 จำเลยได้ปลูกพืชผลและใช้แผงรั้วปิดกั้นทางในช่วงที่ผ่านที่ดินของจำเลยอันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่อาจนำรถยนต์เข้าไปขนส่งยางพาราและพืชผลอื่น ๆ ออกจากที่ดินของโจทก์ได้ขอให้จำเลยเปิดทางเดินโดยรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเดินออกไปเพื่อให้โจทก์ใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์มีสิทธิเข้าดำเนินการรื้อถอนโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 273,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้

จำเลยขอใช้ค่าเสียหายวันละ 1,300 บาท ให้แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะสามารถผ่านเข้าออกทางพิพาทได้

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องอยู่ในที่ปิดล้อมจริง แต่โจทก์มีเส้นทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้หลายทาง โจทก์ไม่เคยใช้รถยนต์ผ่านทางพิพาทมาก่อน ทางพิพาทมีสภาพเป็นทางเดินเท้าที่จำเลยได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำสวนยางของจำเลยเท่านั้น แม้โจทก์จะเคยใช้ทางพิพาทผ่านเข้าออกที่ดินที่ถูกปิดล้อมของโจทก์ก็ตาม แต่เป็นการเข้าออกชั่วคราวด้วยความยินยอมอนุญาตจากจำเลยเท่านั้นจึงไม่ใช่ทางจำเป็น ส่วนทางชักลากไม้ในที่ดินของจำเลยก็หมดสภาพและไม่ได้ใช้ประโยชน์มากกว่า 20 ปี โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเพราะโจทก์เพียงแต่เริ่มเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของโจทก์เท่านั้นแม้โจทก์จะเก็บผลประโยชน์ได้บางส่วนก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทเป็นทางชักลากไม้ที่มีมาแต่เดิมเป็นทรัพย์สินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2)เมื่อจำเลยปิดกั้นทางพิพาท ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดต่อโจทก์โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ จึงมีอำนาจฟ้อง พิพากษาให้จำเลยเปิดทางพิพาทโดยกำหนดความกว้าง 1.50 เมตร มิฉะนั้นให้โจทก์ดำเนินการโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 50 บาท นับแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2526 คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยเปิดทางพิพาทมีความกว้าง 3 เมตร ตลอดแนว คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ว่า มิฉะนั้นให้โจทก์ดำเนินการโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้ยก ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 100 บาท นับ

แต่วันที่ 22 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเปิดทางพิพาท คืบค่าขึ้นศาล  
ชั้นอุทธรณ์ที่เสียเงินมาให้แก่จำเลย นอกจากที่แก้ไข้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล  
ชั้นต้น

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยเป็นประการแรกว่า  
การที่ศาลชั้นต้นเพิกถอนประเด็นข้อพิพาทตามที่ได้กำหนดไว้ในชั้นที่สองสถานแล้ว  
กำหนดประเด็นข้อพิพาทขึ้นมาใหม่ในชั้นทำคำพิพากษานั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์  
ได้บรรยายคำฟ้องให้เห็นว่า ที่ดินของโจทก์อยู่ในที่ปิดล้อม ไม่มีทางออกสู่ถนน  
สาธารณะ โจทก์ใช้เส้นทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่นหลายราย และผ่านที่ดินหนังสือ  
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 195 ของจำเลยเข้าสู่ที่ดินของโจทก์ตามเส้น  
ทางที่ระบุว่าเป็น "ทางชักราบไม้" ตั้งแต่ ปี 2508 ถึงเดือนมิถุนายน 2526 โดยไม่มีผู้  
หนึ่งผู้ใดเข้าเกี่ยวข้องคัดค้าน ตามคำบรรยายฟ้องแสดงให้เห็นว่าทางพิพาทเป็นทาง  
จำเป็น ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า 1. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 2.  
โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 3. ทางพิพาทตามเส้นทางประสีเหลืองในแผนที่พิพาท  
เอกสารหมาย จ.ล.1 เป็นทางจำเป็นและหรือทางภารจำยอมหรือไม่ 4. โจทก์ได้รับ  
ความเสียหายเพียงใดโดยมิได้กำหนดเป็นประเด็นไว้ว่า ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะ  
หรือไม่ไว้ด้วย แต่ครั้งเมื่อทำคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เพิกถอนประเด็นข้อพิพาทข้อ  
2 และ ข้อ 3 เสีย แล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาทสองข้อดังกล่าวเสียใหม่รวมเข้าเป็น  
ข้อเดียวกันในคำพิพากษาว่า โจทก์มีอำนาจให้จำเลยเปิดทางพิพาทตามเส้นประสี  
เหลืองในแผนที่เอกสารหมายจ.ล.1 ได้หรือไม่เพียงใด ตามประเด็นใหม่ครอบคลุม  
ประเด็นข้อที่ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่เข้าไปด้วย ซึ่งประเด็นข้อนี้แต่  
เดิมศาลชั้นต้นมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ และคู่ความทั้งสองฝ่ายมิได้โต้  
แย้งหรือคัดค้านไว้ จึงถือได้ว่าคู่ความได้สละประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว ดังนั้น ที่ศาล

ชั้นต้นกลับนำประเด็นข้อที่ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ขึ้นมาวินิจฉัยอีก ย่อมเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและเป็นการไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะ ไม่เป็นการนอกฟ้องนอก ประเด็นนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคดีได้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ประกอบกับคู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบในประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ในตอนแรกครบถ้วนบริบูรณ์แล้วศาลฎีกาจึงเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยทีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยใหม่อีก

จำเลยฎีกาในประการต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่และทางพิพาทตามเส้นประสีเหลืองในแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.ล.1 เป็นทางจำเป็นและหรือทางภาระจำยอมหรือไม่นั้น เห็นว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทอย่างการจำยอม และได้สิทธิมาโดยอายุความอย่างไร คดีจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอมหรือไม่ คงมีปัญหาว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นหรือไม่เท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของโจทก์มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทหรือทางชักลากไม้ที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ผ่านเข้าออกสู่ที่ดินของโจทก์ ตั้งแต่ ปี 2508 จนถึงเดือนมิถุนายน 2526 แม้จะมีทางอื่นเข้าออกได้อีกทางหนึ่ง แต่ก็เป็นทางเดินขึ้นเขามีลักษณะลาดชันไม่อาจใช้รถยนต์วิ่งผ่านได้ และไกลกว่าทางพิพาท ทางพิพาทจึงเป็นทางจำเป็น เมื่อจำเลยปิดทางพิพาทดังกล่าวเสีย ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องส่วนทางพิพาทตามเส้นประสีเหลืองในแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.ล.1 มีความกว้างเพียงใดนั้น ได้ความว่าสภาพทางพิพาทเป็นทางที่ชาวบ้านลากไม้โดยใช้ "นวน" กว้างประมาณ 1 เมตรเศษ นอกจากร่องรอยเดินเท้าแล้ว ไม่มีร่องรอยทางรถยนต์ ประกอบกับศาลชั้นต้นเผชิญสืบทาง

พืพาทและกำหนดความกว้างของทางพืพาท 1.50 เมตร ตามคำพืพากษาของศาลชั้น  
ต้นเช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พืพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยเปิดทางพืพาทมีความกว้าง 1.50 เมตรตลอดแนว  
ตามเส้นประสีเหลืองในแผนที่พืพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 1,000 บาท  
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพืพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พืพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |